

1500424-23.2022.8.26.0575

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: WYLDENSOR MARTINS SOARES

Comarca: São José do Rio Pardo

Foro: Foro de São José do Rio Pardo

Vara: 1ª Vara

Data de Disponibilização: 20/10/2022

... Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2185819/2022 - DEL.SEC.CASA BRANCA, 26038253 -

DEL.SEC.CASA BRANCA, 2185819 - DEL.POL.S.J.DO RIO PARDO

Autor:

Justiça Pública

Réu:

MAICON HENRIQUE DOS SANTOS SILVÉRIO e outros

Réu ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de São José do Rio Pardo

Foro de São José do Rio Pardo

1ª Vara

Praça dos Três Poderes, nº 3, São José do Rio Pardo-SP - cep 13720-000

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1500424-23.2022.8.26.0575 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500424-23.2022.8.26.0575

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2185819/2022 - DEL.SEC.CASA BRANCA, 26038253 -

DEL.SEC.CASA BRANCA, 2185819 - DEL.POL.S.J.DO RIO PARDO

Autor:

Justiça Pública

Réu:

MAICON HENRIQUE DOS SANTOS SILVÉRIO e outros

Réu Preso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). WYLDENSOR MARTINS SOARES

Vistos.

Trata-se de ação penal em desfavor de SAN DIEGO AUGUSTO FERNANDES FLORA, MAICON

HENRIQUE DOS SANTOS SILVÉRIO e NATAN AURELIANO DA SILVA, como incurso no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06, c.c. artigo 29, caput, do Código Penal, eis que no dia 10 de julho de 2022, por volta das 11h55min, na Avenida dos Braghetas, Carlos Cassuci, nesta cidade e comarca, agindo em concurso de desígnios entre eles e com os outros dois indivíduos não identificados, vendiam e traziam com eles, 08 (oito) invólucros plásticos contendo cocaína, pesando 6,00 gramas, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar.

A denúncia de págs. 134/136 veio amparada no Inquérito Policial - Prisão em Flagrante - de págs. 01/114.

O réu Natan foi citado às págs. 151; Maicon foi citado às págs. 149 e o réu San Diego foi citado às páginas 153.

Apresentaram defesa prévia às páginas 161/165. Aduzem, em síntese, a inépcia da denúncia, uma vez que ela traz os fatos de forma genérica, imputa as condutas de forma ampla e não descreve as ações praticadas por cada um dos réus. Requer a absolvição dos acusados, bem como seja concedida a liberdade provisória aos réus.

A denúncia foi recebida ao 02 de setembro de 2022. Na oportunidade, restou mantida a prisão preventiva em desfavor dos réus. Designou-se data para audiência de instrução, debates e julgamentos. (págs. 166/169).

Durante referida solenidade, foram ouvidas as testemunhas arroladas pelas partes, bem como foi procedido ao interrogatório dos acusados, conforme termo e mídia que se encontram armazenados no SAJ - pgs. 234/236.

Na fase do art. 402 do CPP, nada foi requerido.

Em memoriais, o Ministério Público do Estado de São Paulo requereu a procedência da ação penal. Indica o Parquet que as versões dos policiais são suficientes para demonstrar a mercancia, ao passo que as negativas dos réus são inconvincentes. Destaca que nada desabona as palavras dos policiais, ao passo que a versão dos réus é repleta de contradições que expôs circunstanciadamente nas pgs. 243. Ressalta que Natan é reincidente, assim como San Diego. Maicon, por sua vez, dedica-se a atividades criminosas, conforme processo 0007742-70.2019.8.26.0015. Entende adequado o regime fechado aos reincidentes e semi-aberto para Maicon.

A Defesa, por sua vez, requer a absolvição por falta de provas ou a desclassificação da conduta imputada a San Diego, conforme item I de pgs. 252 dos memoriais, seguindo no mesmo sentido em relação a Natan -item II de pgs. 253 e Maicon - item III de pgs. 254. Subsidiariamente, ressalta, em relação a Maicon, a impossibilidade de sopesar em seu desfavor a prática de atos infracionais para afastar a minorante do § 4º do art. 33, ressaltando, ainda, sua menoridade relativa. No que tange aos corréus alega que não há agravantes, conforme teses melhores expostas nas pgs. 251/257.

DECIDO.

1 -) SÍNTESE PROBATÓRIA

1.1 -) Das provas da materialidade.

A materialidade delitiva está demonstrada pelo auto de exibição e apreensão em flagrante (págs. 15), requisição de IC (pág. 17/18), auto de constatação preliminar a págs. 19, além dos laudos periciais de págs. 200/205 que indicam a massa líquida de 1,6 gramas de cocaína - pg. 204.

Houve, pois, modificação do mundo naturalístico pela conduta, restando atendido o princípio da materialização do fato.

1.2 -) Das provas da autoria.

Eis a síntese da prova oral angariada durante a instrução em Juízo:

Ana Letícia Avelar Zenaro de Souza, informa que no dia dos fatos estavam de serviço e sabedores da intensa traficância na biqueira do "Bronx" visualizaram 5 indivíduos naquele local e constataram algumas vendas. Resolveram abordar. Dois correram para cima do pasto e três no sentido oposto, para baixo. Fizeram o cerco e abordaram eles na rua. Na abordagem não encontraram nada com eles, mas no caminho que eles fizeram encontraram pinos vazios, 8 pinos de cocaína e uma celular. O San Diego era conhecido, mas não por motivos de tráfico. Os outros dois não eram conhecidos. Eles disseram que correram porque os outros dois mandaram eles correrem. Os cinco se revezavam nas funções de traficar. Não vai lembrar o que cada um deles faziam, mas transeuntes e veículos se aproximavam. Foi apreendido no caminho inverso uma quantidade de dinheiro. Foi pouco dinheiro. Acha que uma nota de R\$ 10,00 e duas de R\$ 2,00. O Zocal não sabe dizer se conhecia os demais réus. Os indivíduos que fugiram não conseguiram identificar. É uma área de pasto grande e como eles correram em direção opostas não foi possível. Viu os réus dispensando algo. À distância não deu para identificar o que era. Chegou a visualizar os cinco "na função" ali, os cinco estavam vendendo, estavam na função de tráfico. Ficavam dois em cima da pedra e o restante ficam uns olhando para baixo e outros olhando para cima porque podem chegar veículos pelos dois lados. Um atende quem vem de baixo e outro quem vem de cima. As drogas geralmente ficam em cima da pedra. No caso de hoje a droga ficava sobre a pedra. Dois ficavam de olheiros. E os outros faziam a venda. Não se recorda quem ficava como olheiros e quem fazia a venda diretamente.

Júlio César de Araújo Zocal relata que estava de serviço junto com a soldado Letícia e rumaram até a avenida dos Braghetas onde há a pedra do Bronx, local de intensa traficância onde ocorreram diversas prisões. Conseguiram identificar 5 indivíduos que pareciam atuar em uma "linha de produção". Cada um tinha uma função para servir os usuários que ali passavam. Um buscava droga, outro escondia, outro guardava o dinheiro. Puderam observar claramente umas cinco vendas de drogas naquele local. Diante do que observaram, viram onde os réus se abaixavam para pegar drogas. O local é de difícil acesso. Área de pasto. Apenas conseguem chegar pela área de pasto. Pela rua dificilmente conseguem fazer a abordagem porque eles se evadem. No dia, logo que perceberam a aproximação da viatura dois deles se embrenharam na mata da parte de cima e os outros 3 entraram na parte de baixo, numa mata. Acompanhou tais elementos a uma certa distância. Eles dispensavam objetos enquanto corriam. Foram abordados no bairro Eduardo Cassucci. Em busca pessoal nada encontraram, mas ao retornarem pelo trajeto da corrida localizaram um pacote com diversos pinos de cocaína vazios e mais oito pinos de cocaína já prontos para venda, além de celular e dinheiro, pouco dinheiro. Questionados eles informaram que realmente estavam ali, mas iriam apenas adquirir drogas. Eles correram porque os indivíduos que correram mandaram que corressem. Todavia, eles foram visualizados diretamente vendendo. Ali raramente usuários de drogas permanecem. Os traficantes

não aceitam porque atrai a atenção de outras pessoas ou até da polícia. Os carros param e são atendidos por pessoas. Ficaram fazendo a observação à distância por uns 30 ou 40 minutos. Todos os réus permaneciam ali. San Diego já era conhecido por tráfico de drogas. Natan já era conhecido.

O réu, San Diego Augusto Fernandes Flora, em oportunidade de autodefesa disse que tem 22 anos. Trabalha na zona rural. Mora com seu pai. Faz uso de cocaína. Estudou até a sexta série. Nunca foi internado por causa de drogas. Conhece os corréus porque moram no mesmo bairro. Mora no bairro Chico Xavier. Ouviu o que os policiais disseram. A Ana Letícia até falou que nunca viu o réu traficando. Foi apenas pegar pinos e viram a viatura e correram. Não estavam traficando. Foram juntos comprar drogas. Os oito pinos encontrados pertenciam ao grupo. Pagaram R\$ 80,00. O depoente tinha recebido da roça e compraram a droga. Cada um deu pouco. Tinha apenas os R\$ 14,00 que foram apreendidos de resto. Dos R\$ 80,00, cada um pouco. A parte do depoente foi R\$ 30,00. Tinha comprado droga ali antes e que havia droga ali. Não traficava não. Trabalhava todo dia. Os outros dois que correram foi quem lhe venderam a droga. Eles encontraram cápsulas vazias a polícia falou que lhes pertencia. Está assumindo apenas os oito pinos e os R\$ 14,00. Tem um pai de 83 anos e queria estar cuidando dele.

O réu, Maicon Henrique dos Santos Silvério, em oportunidade de autodefesa disse que já foi processado quando era menor. Tem 20 anos. Mora com sua mãe. Frequentava o CAPS para dependente químico. Não estava trabalhando. Estudou até a oitava série. Foi internado. A última vez faz dois anos. Conhece os corréus porque eles moram no mesmo bairro. Ouviu o que os policiais disseram. Na verdade, foi lá apenas para comprar. A viatura apareceu e se assustou e correu. O San Diego e Natan foram juntos. A droga apreendida não lhes pertencia. Não chegou a comprar droga nenhuma. A polícia apreendeu R\$ 10,00 com o depoente. Era o único dinheiro que tinham para usar droga. O pino custa R\$ 10,00. Iam comprar 1 pino para dividir para os três. Os outros dois indivíduos que a polícia diz que correu não conhece. Na hora que a polícia chegou, demorou 2 minutos e a viatura já apareceu.

O réu, Natan Aureliano da Silva, em oportunidade de autodefesa disse que nunca foi preso antes. Estava trabalhando na colheita de limões sicilianos. Tem registro na carteira, mas tinha perdido o serviço há um mês. Tem 23 anos. Mora com sua mãe. Estudou até o sétimo ano. Usa cocaína. Nunca foi internado por uso de cocaína, mas sua família estava indo atrás dos papéis para lhe internar. Conhece os réus desde pequenos e tinha estudado com eles. No dia dos fatos estavam mesmo passando por lá porque iam comprar 1 pino de cocaína. Os meninos que estavam lá falaram para eles entrar lá. Falaram para o depoente subir lá dentro. Nesse meio tempo a viatura veio. Correram para outro lugar e foram abordados pela viatura que lhes levou novamente no local de venda de drogas. Os oito pinos não eram do depoente. Não tinha conseguido comprar. O dinheiro que tinha era do depoente. Era R\$ 14,00. Com os R\$ 14,00 iam comprar um pino para dividir para os 3. A polícia encontrou cápsulas vazias. Viu eles encontrando sim. Não viu ninguém dispensando as cápsulas vazias. Os R\$ 14,00 foram apreendidos com o próprio depoente. O San Diego e o Maicon não tinham dinheiro. A versão de San Diego está errada. Apenas correram e não compraram droga.

2 -) DO DIREITO APLICÁVEL.

2.1 -) VALIDADE DO DEPOIMENTO POLICIAL

Ab initio, é preciso consignar a validade do testemunho policial, pois “goza de presunção de credibilidade”.

Quanto às falas dessas testemunhas, à guisa de ter o agente atuado no feito, tenho por oportuno destacar a sua aproveitabilidade, tanto como a de qualquer pessoa. É que o depoimento do policial, em razão de sua condição de agente da Administração Pública, presume-se verdadeiro e merece crédito, mormente porque se mostra firme, coeso e em consonância com o conjunto probatório dos autos. Tal presunção, obviamente, admitiria prova em contrário, que, entretanto, não foi produzida pela defesa.

A credibilidade do depoimento de policiais tem tanta força quanto a de outros indivíduos. O fato de que cabe a eles a atribuição de prevenir e reprimir o crime não tem o condão de invalidar, de per si, a prova decorrente de seus testemunhos.

Por mero preconceito ou suspeita infundada, não pode o Estado-Juiz entender tais depoimentos imprestáveis para lastrear sentença condenatória. O depoimento policial tem plena força probatória, se não houver nenhuma razão plausível, cabalmente comprovada nos autos, para se lhe retirar a credibilidade.

O Egrégio Tribunal de Justiça de São Paulo chegou a proclamar: “Não compromete a credibilidade da palavra dos policiais eventual violência contra os presos ou variação sobre pormenores a respeito do fato criminoso.” (TJSP, Ap. 203.471-3/0, 5.^a Câ. J. 26.9.1996, rel. Des. Dante Busana, RT 737/602).

Preceitua o artigo 202 do CPP que “toda pessoa pode ser testemunha”, logo, é indiscutível que os policiais, sejam eles os autores da prisão do réu ou não, podem testemunhar, sob compromisso de dizer a verdade e, assim, sujeitos às penas do crime de falso testemunho e denúncia caluniosa.

Além disso, desconsiderar a validade probatória de um depoimento levando-se em conta, apenas, a profissão de uma pessoa (por exemplo: policial militar ou civil), nada mais é do que tratamento discriminatório em violação do princípio da igualdade e temor de enfrentar o fato e o seu valor correspondente, postura essa temerária ao direito.

O escólio pretoriano bem elucida a questão:

“O valor do depoimento testemunhal de servidores policiais – especialmente quando prestado em juízo, sob a garantia do contraditório – reveste-se de inquestionável eficácia probatória, não se podendo desqualificá-lo pelo só fato de emanar de agentes estatais incumbidos, por dever de ofício, da repressão penal. O depoimento testemunhal do agente policial somente não terá valor, quando se evidenciar que esse servidor do Estado, por revelar interesse particular na investigação penal, age facciosamente ou quando se demonstra – tal como ocorre com as demais testemunhas – que as suas declarações não encontram suporte e nem se harmonizam com outros elementos probatórios idôneos” (STF – 1.^a Turma – HC 74.608-0/SP – Rel. Min. Celso de Mello – DJU de 11.04.97, pág. 12.189).

“A SIMPLES CONDIÇÃO DE POLICIAL NÃO TORNA A TESTEMUNHA IMPEDIDA OU SUSPEITA – STF, RTJ 68/64 E 168/199” (Damásio E. de Jesus, Código de Processo Penal Anotado, Saraiva, 19.^a Edição, 2002, p. 176 e 182).

Ainda nesse sentido:

“HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. NULIDADE DA SENTENÇA CONDENATÓRIA. INSUFICIÊNCIA DAS PROVAS DE ACUSAÇÃO. DEPOIMENTOS PRESTADOS EM JUÍZO POR AUTORIDADES POLICIAIS. VALIDADE. REVOLVIMENTO DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. É da jurisprudência desta Suprema Corte a absoluta validade, enquanto instrumento de prova, do depoimento em juízo (assegurado o contraditório, portanto) de autoridade policial que presidiu o inquérito policial ou que

presenciou o momento do flagrante. Isto porque a simples condição de ser o depoente autoridade policial não se traduz na sua automática suspeição ou na absoluta imprestabilidade de suas informações. Tratando-se de sentença condenatória escorada não apenas nos depoimentos prestados em Juízo pelos policiais, como também nos esclarecimentos feitos pelas próprias testemunhas da defesa, não é possível rever todo o acervo fático-probatório do feito criminal para perquirir se as provas a que se referiu o magistrado de primeira instância são ou não suficientes para produzir uma condenação. (...) Ordem denegada." (HC 87662, Relator(a): Min. CARLOS BRITTO, Primeira Turma, julgado em 05/09/2006, DJ 16-02-2007 PP-00048 EMENT VOL-02264-02 PP-00280 LEXSTF v. 29, n. 339, 2007, p. 417-421). (grifos meus)

Outrossim, é de se ter em conta que em se tratando de tráfico de entorpecentes, opera-se a "lei do silêncio", extremamente difícil arrolar testemunhas dispostas a testemunhar contra traficantes.

2.2) DA VALORAÇÃO PROBATÓRIA

Diante do panorama probatório, conclui-se que a conduta praticada pelos réus amolda-se perfeitamente ao tipo penal esculpido no artigo 33, caput, da Lei 11.343/06 (Nova Lei de Drogas), consideradas as circunstâncias que permearam a apreensão dos entorpecentes.

É de se ressaltar que as normas incriminadoras (artigos 28 e 33 da Lei 11.343/2006) encerram uma potencialidade abrangente de duas condutas, dependendo da conduta do réu a justa e exata caracterização, como usuário ou traficante, exigindo, para o reconhecimento do tipo penal previsto no artigo 28 da lei 11.343/06, prova a ser produzida pela defesa de que a substância entorpecente não se destinava ao comércio ilícito.

A negativa de autoria dos réus nada mais revela do que o intuito de não produzirem provas contra si mesmos, o que é plenamente lícito, mas insuficiente para desfigurar a tese acusatória que vem amparada pelo depoimento dos policiais e prova da materialidade.

O local da prisão é amplamente conhecido deste Juízo e as regras da experiência judicante adquirida há mais de seis anos nesta comarca ensinam que a biqueira do "Bronx" não admite permanência de usuários. Trata-se de local de intensa traficância rotativa, ou seja, os usuários aproximam-se a pé ou com veículos, motocicletas, pegam as drogas e rapidamente deixam o local.

Tal realidade não está calcada em qualquer subjetividade deste julgador, mas ressaí do teor da prova oral acima produzida, em especial o depoimento do Cabo Zocal, que indagado especificamente do perfil genérico da traficância naquela "biqueira", esclareceu: "Ali raramente usuários de drogas permanecem. Os traficantes não aceitam porque atraí a atenção de outras pessoas ou até da polícia. Os carros param e são atendidos por pessoas."

Não se pode olvidar a apreensão de expressiva quantidade de material para embalagem de drogas - 267 invólucros plásticos vazios - o que também robustece a versão acusatória de exercício da traficância pelos réus, tal como descrita pelos policiais militares.

Os réus, por sua vez, não apresentam relatos minimamente consistentes. A propósito,

o Juízo vale-se dos apontamentos ministeriais, suficientemente esclarecedores: "O mesmo não pode ser conferido à palavra dos acusados que trouxeram depoimentos divergentes sobre o que realmente teria ocorrido. SAN DIEGO relatou em juízo que os oito pinos de drogas encontrados pela polícia eram deles. Cada um dos acusados havia dado certa quantia em dinheiro para totalizar o valor da droga. Contudo, os outros acusados disseram que a droga encontrada não lhes pertencia e que iriam comprar apenas um pino de droga e dividir entre os três." (pgs. 243).

A respeito da citação de trecho da argumentação acusatória, prudente dizer que é pacífico no âmbito do STF e do STJ o entendimento de ser possível a fundamentação per relationem ou por referência ou por remissão, não se cogitando nulidade ou ofensa ao artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal, desde que os fundamentos existentes aliunde sejam reproduzidos no julgado definitivo (principal). Neste sentido: E. STF: MS 27350 MC/DF, Relator Min. Celso de Mello, DJ de 04.06.2008; Emb. Decl. no Ag. Reg. no Recurso Extraordinário com Agravo nº 692.087/DF, 1ª Turma do STF, Rel. Rosa Weber. j. 12.08.2014, unânime, DJe 29.08.2014 e no STJ: REsp 1.426.406/MT, Rel. p/Acórdão Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, DJe 11.05.2017).

Assim, cabível a reprodução dos principais trechos apontados pela acusação e que estão amparados no acervo probatório coligido durante a instrução processual.

Pertinente sinalizar, ainda, que a própria Lei admite tal técnica de fundamentação. A propósito, tem-se o § 3º do art. 2º do Decreto 9.830/2019 que regulamentou os artigos 20 a 30 da Lei de Introdução às Normas no Direito Brasileiro – Lei 4.657, DE 04/09/1942.

A respeito das teses defensivas de insuficiência de provas, tem-se que eventual dúvida, para que fosse capaz de beneficiar os réus, deveria estar alicerçada em contraprovas capazes de demonstrar ao Juízo a possibilidade de realidade diversa. No caso concreto, no entanto, apenas o Ministério Público esforçou-se para comprovar o que consta na denúncia, ao passo em que não se encontram nos autos elementos capazes de comprovar realidade diversa da que vem externada pela prova acusatória.

Apropriados os ensinamentos de FRAMARINO DEI MALATESTA, o qual afirma que "o princípio ontológico coloca o ônus de prova a cargo da acusação, quando considera as duas asserções contrárias, do acusador e acusado, antes da produção de provas. Mas, desde o momento em que o acusador reuniu as suas provas para sustentar a sua asserção, se o acusado, em contradição à asserção do acusador, emite simples asserção contrária, não faz mais que contrapor uma asserção não provada a uma provada e como esta tem direito de ser tomada como verdadeira de preferência a não provada, sendo a presunção da verdade, neste segundo momento, a favor do acusador, a obrigação da prova incumbe ao acusado" (A Lógica das Provas em Matéria Criminal, Campinas: Conan 1995 v. I p. 45-146 – destaque do Juízo).

À míngua de contraprovas nada autoriza que o Juízo fundamente a sentença em sentido oposto àquele que vem esclarecido pelo acervo probatório angariado pelo Parquet, sob pena de engendrar-se sentença manifestamente contrária à prova dos autos.

Destarte, não há resquício de dúvida de que todos estes fatores conjugados - depoimentos harmônicos dos policiais, prova da materialidade, inconsistência nas autodefesas dos réus evidenciam a absoluta preponderância dos elementos angariados pela acusação que logrou fazer com que o fiel da balança pendesse no sentido da pretensão punitiva.

A tese de desclassificação também não merece respaldo. Natan e Maicon negam a propriedade das drogas seja para qual finalidade for. Disseram que as drogas não lhes pertencia. Destarte, não poderiam estar portando as drogas para uso pessoal,

na medida em que negam o porte para qualquer finalidade.

O único que assume a posse de 8 porções é San Diego, Mas, como visto, sua versão está em confronto com a palavra dos policiais e nem mesmo os corréus prestaram declarações que pudessem cancelar a versão de Diego.

Sendo as versões dos réus inconciliáveis, a única conclusão plausível é que distanciam-se do que de fato ocorreu.

No que tange à alegada drogadição dos réus, é sabido que a condição de usuário não é incompatível com a traficância. Noutras palavras, "Ainda que admissível a circunstância de que o réu padeça de toxicomania, a alegação de ser usuário de droga tem-se que em nada modifica a imputação, pois perfeitamente conhecida a figura do "viciado-traficante"" (STF-2ªTurma, HC-MC73.197/GO, Rel. Min. Maurício Corrêa, DJ 22.11.1996).

Sobre a questão manifestou-se a Colenda Corte Paulista: - "A alegação de viciado não obsta o reconhecimento da figura do traficante, mormente na hipótese vertente, em que ambas se mesclam num mesmo agente, preponderando a última, de maior gravidade" (TJSP HC 42.229-3 Rel. Onei Raphael RJTJSP101/498).

Presente a tipicidade delitiva e não havendo justificativas ou dirimentes capazes de afastar a antijuridicidade da conduta e culpabilidade dos réus, a condenação é medida necessária para a concretização dos escopos de prevenção geral positiva e prevenção especial colimados pelo sistema punitivo, além de restabelecer o princípio da prevalência do Direito e atestar a vigência da norma penal violada.

Ex positis, JULGO PROCEDENTE a denúncia de págs. 134/136 para CONDENAR SAN DIEGO AUGUSTO FERNANDES FLORA, MAICON HENRIQUE DOS SANTOS SILVÉRIO e NATAN AURELIANO DA SILVA, como incursos no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06, c.c. artigo 29, caput, do Código Penal, passando a dosar-lhes a pena, nos termos do artigo 68 do Código Penal e artigo 42 da Lei de Drogas.

Quanto ao réu SAN DIEGO AUGUSTO FERNANDES FLORA:

Analisadas as diretrizes do artigo 59 do Código Penal e 42 da Lei 11.343/2006, observa-se que o modus operandi não recomenda que seja acentuada a pena, pois a culpabilidade é normal à espécie.

Poucos elementos foram coletados acerca de sua conduta social e personalidade, razão pela qual não influenciam negativamente a dosimetria. Além disso, deixo transparecer que tais circunstâncias judiciais se analisadas em detrimento do réu evidenciam acolhimento do "direito penal de autor", fenômeno indesejável e antigarantista que não conta com o aval deste Juízo.

Na análise determinada pelo art. 42 da Lei de Drogas tem-se que o critério "quantidade" compreende duas variáveis:

1ª O peso, massa, das substâncias propriamente ditas não recomenda acréscimo, pois a apreensão foi de 1,6 gramas de cocaína, conforme apontado no LAUDO PERICIAL de págs. 200/205.

2ª A diversidade, variedade das substâncias, pois em "quantidade" de drogas podemos ter pequenas ou grandes porções de 1,2,3 ou mais drogas diferentes.

Analisando os itens o Juízo não encontra campo para acréscimo na reprimenda, pois a

quantidade-diversidade (no caso uma - cocaína) não impõe aumento de pena e a quantidade-massa é pequena.

Cabe ressaltar, ainda, a exasperação também não é medida a se impor, neste caso, em relação à natureza das drogas. Cocaína é um entorpecente considerado "comum" encontrados em qualquer cidade e apreendido com frequência diária em São José do Rio Pardo.

O motivo do delito está albergado na própria tipicidade da traficância enquanto atividade mercantil para obtenção de lucro ilícito.

As circunstâncias do delito não destoam daquelas em que ocorrem crimes desta natureza, ao passo que não há elementos para aferir se as consequências foram graves.

À luz dessas circunstâncias é que fixo a pena-base privativa de liberdade para o crime capitulado no artigo 33, caput da Lei 11.343/2006, no mínimo legal, fixando-a em 5 anos de reclusão e 500 dias-multa estes fixados na proporção de 1/30 do salário-mínimo vigente à época do fato, cada dia-multa, diante da condição econômica desfavorável do réu.

San Diego é reincidente, pois consta condenação por infração ao artigo 157, § 2º, inciso II do Código Penal - feito nº 0018038-48.2019.8.26.0502 ou 1500105-43.20219-2ª Vara desta Comarca, cujo trânsito em julgado operou-se aos 30.11.2020 - pg. 75.

Agravo a pena em 1/6, guindando-a ao patamar de 5 anos e 10 meses de reclusão e 583 dias-multa. Não há atenuantes.

Inviável a incidência da causa de diminuição de pena prevista no § 4º do art. 33 da Lei 11.343/2006, exatamente por força da reincidência.

À míngua de causas gerais ou especiais de diminuição ou aumento de pena, torno em definitiva a sanção supra.

Havendo condenação por crime equiparado a hediondo (artigo 2º da Lei 8.072/90) e sendo reincidente o réu, o regime inicial de cumprimento da pena é o FECHADO (artigo 2º, § 1º da Lei 8.072/90).

Em que pese o reconhecimento incidental da inconstitucionalidade do referido dispositivo (HC 111.840 27.06.2012 Rel. Min. Dias Toffoli), o tráfico de drogas sem o reconhecimento da forma privilegiada é a conduta mais perniciosa à Sociedade. Estimula inúmeros outros crimes, formação de organizações criminosas, destrói famílias de usuários, instala o caos nas escolas. A complacência do Estado com este tipo de crime (contrariamente aos comandos constitucionais indicativos de necessário rigor) tem contribuído para que o mal se alastre. A Sociedade, desprotegida, vê-se num caminho sem volta. Traficantes fazem o que bem entendem e contam com a fragilidade do sistema punitivo que está sendo direcionado para o fomento do injusto na medida em que não oferece combate forte o suficiente para desestimular o comércio espúrio de entorpecentes.

Portanto, este Juízo apenas reconhece a possibilidade de regime diverso do fechado nos estritos limites da decisão do E. STF que na sessão do dia 23.06.2016, entendeu que o chamado tráfico privilegiado, no qual as penas podem ser reduzidas, conforme o artigo 33, parágrafo 4º, da Lei 11.343/2006 (Lei de Drogas), não deve ser considerado crime de natureza hedionda. A discussão ocorreu no julgamento do Habeas Corpus (HC) 118533, que foi deferido por maioria dos votos.

Quanto ao réu NATAN AURELIANO DA SILVA:

Reporto-me aos fundamentos expostos em relação ao corréu para fixar a pena no mínimo legal de 5 anos de reclusão e 500 dias-multa.

Registre-se que a condenação nos autos 1500027-32.2020.8.26.0575 por tráfico de drogas ainda não transitou em julgado – pgs. 70, o que impede sua utilização para fins de maus antecedentes, na forma da súmula 444 do E. STJ.

O réu é reincidente, devendo incidir a respectiva agravante, por força de condenação nos autos 1500657-20.2021.8.26.0360 cujo trânsito em julgado operou-se para a defesa aos 16.12.2021 – pgs. 69.

Com o acréscimo de 1/6 sua pena equipara-se a do corréu San Diego, atingindo o patamar de 5 anos de reclusão e 583 dias-multa.

Inviável a concessão da minorante do § 4º do art. 33 da Lei de Drogas, diante da reincidência.

Pelos mesmos fundamentos expostos alhures, havendo prática de crime equiparado a hediondo e reincidência, o regime aplicável é o FECHADO.

Quanto ao réu MAICON HENRIQUE DOS SANTOS SILVÉRIO:

Na primeira etapa sua pena também deve ficar no mínimo de 5 anos de reclusão e 583 dias-multa.

Sem agravantes, pois diferentemente dos demais réus, Natan não é reincidente. Sua menoridade relativa é inócua, diante do disposto na súmula 231 do E. STJ.

Inviável a concessão da minorante do § 4º do art. 33 da Lei de Drogas, pois o réu dedica-se a atividades criminosas desde a menoridade, conforme verifica-se no processo 0007742-70.2019.8.26.0015 – certidão de pgs. 78 - onde teria cumprido medida socioeducativa por ato infracional análogo ao tráfico de drogas.

Não se pode perder de vista que somente é ato infracional aquilo previsto como crime. Diz o artigo 103 da Lei 8.069/1990: "Art. 103. Considera-se ato infracional a conduta descrita como crime ou contravenção penal." (destaque do Juízo).

Assim, a conduta praticada pelo réu enquanto menor tem natureza criminosa (prevista como crime), porém recebe o tratamento diverso sob a "etiqueta" de ato infracional para os fins da Lei 8.069/1990.

Mas, como a conduta é necessariamente considerada criminosa, sob pena de não poder o menor responder pela prática de ato infracional, soa evidente para este Juízo que a sua prática é suficiente para configuração do óbice "não se dedique às atividades criminosas", previsto no art. 33, § 4º da Lei de Drogas.

No mesmo sentido:

TRF4-) PENAL. EMBARGOS INFRINGENTES. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA DAS PENAS. ART. 33, § 4º, DA LEI 11.343/06. CAUSA DE ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO DE PENA. INAPLICABILIDADE. ATOS INFRACIONAIS. DEDICAÇÃO A ATIVIDADES CRIMINOSAS. 1. Incabível a aplicação da causa especial de diminuição de pena prevista no artigo 33, § 4º, da Lei 11.343/06, quando demonstrado que o réu praticou diversos atos infracionais, os quais, embora não configurem reincidência ou maus antecedentes, revelam a dedicação a atividades criminosas, restando ausente um dos requisitos legais necessários à aplicação da referida minorante. Precedente do Superior Tribunal de Justiça. 2. Hipótese em que, conquanto o réu não ostente antecedentes criminais, nem haja prova de que integre organização criminosa, a não aplicação da

causa de redução de pena foi fundamentada na existência de mais de 10 (dez) processos instaurados, os quais revelam o histórico de atos infracionais do acusado (estupro, roubo, furto, receptação, lesões corporais, ameaça, tentativa de homicídio e delitos de trânsito), restando evidenciada a sua dedicação a atividades criminosas e, conseqüentemente, o óbice expressamente previsto na norma legal. (Embargos Infringentes e de Nulidade nº 5000509-04.2014.404.7210, 4ª Seção do TRF da 4ª Região, Rel. Márcio Antônio Rocha. j. 16.07.2015, maioria, DE 21.07.2015).

E ainda: Apelação Criminal nº 5004789-63.2014.404.7001/PR, 8ª Turma do TRF da 4ª Região, Rel. Simone Barbisan Fortes. j. 30.07.2014, maioria, DE 13.08.2014; Apelação nº 0008236-84.2011.8.08.0024 (024110082369), 1ª Câmara Criminal do TJES, Rel. Ney Batista Coutinho. j. 27.03.2013, unânime, DJ 05.04.2013.

Por sua correção, merece ser prestigiado o ENUNCIADO Nº 32 do FONAJUC: Havendo registro de ato infracional praticado pelo réu, a redução prevista no artigo 33, § 4º, da Lei 11.343/06 poderá ser afastada.

Torno em definitiva a pena supra de 5 anos de reclusão e 583 dias-multa, calculados a exemplo da base de cálculo fixada para os demais réus.

Mantido o caráter hediondo da conduta, o regime inicial não deve divergir do regime indicado aos corréus, qual seja, o FECHADO, como determina a Lei de Crimes Hediondos. Ademais, nos termos do HC 118533, apenas a concessão do privilégio retira o caráter hediondo da conduta, o que não ocorre nos caso de Maicon.

Acrescente-se que apenas o regime inicial fechado tem o condão de romper com a "teia criminosa" na qual estava inserido. Como se vê, o réu estava mancomunado com outros elementos e se revezava na traficância na "biqueira do Bronx". Outros indivíduos fugiram e certamente permanecem "na função". Permitir o regresso precoce à sociedade deixará o réu novamente livre para retomar os contatos com tais elementos, com fornecedores de maior envergadura e antigos "clientes", o que não se mostra recomendável, notadamente diante de prisão tão recente, ocorrida há apenas 3 meses.

Não permito que os réus recorram em liberdade, pois permanecem hígidos os fundamentos das prisões preventivas, restando fortalecidos os indícios de autoria, diante da sentença penal condenatória após cognição exauriente. Portanto, respondendo ao processo presos, assim devem permanecer após a confirmação de suas culpas em veredito obtido após o devido processo legal, ainda que sujeito a recurso.

Recomendem-se nos estabelecimento prisional em que se encontram.

Nos termos dos artigos 804 e 805 do CPP, CONDENO os réus ao pagamento das custas processuais que fixo em 100 UFESP's. Saliento que "A condição de beneficiário da Justiça Gratuita não isenta o condenado do pagamento das custas. Eventual isenção poderá ser avaliada à época da execução da sentença condenatória, quando serão apreciadas as reais condições quanto ao estado de pobreza do réu e à possibilidade do pagamento das custas processuais sem prejuízo de seu sustento próprio ou de sua família. Precedentes. Recurso desprovido, nos termos do voto do relator" (STJ, REsp 343.689/MG, Rel. Min. Gilson Dipp, T5, DJ 22.04.03, p. 253).

A cobrança fica suspensa nos termos do art. 98, § 3º do NCPC c.c art. 3º do CPP.

Oportunamente, após o trânsito em julgado desta decisão, adotem-se as seguintes providências:

1 - Expeçam-se guias de execução definitiva;

- 2 - Proceda-se ao recolhimento dos valores atribuído a título de pena pecuniária, em conformidade com o disposto no artigo 686 do Código de Processo Penal;
- 3 - Oficie-se ao Tribunal Regional Eleitoral deste Estado, comunicando a condenação, com sua devida identificação, acompanhada de fotocópia desta decisão, para cumprimento do disposto nos artigos 71, §2º do Código Eleitoral c/c inciso III do artigo 15 da Constituição da República;
- 4 - Oficie-se ao órgão responsável pelo cadastro de antecedentes criminais deste Estado para as anotações necessárias;
- 5 - Se patrocinado por advogado(a) dativo(a) arbitro os honorários, conforme regras do convênio. Oportunamente, expeça-se certidão.
- 6 - DECRETO o perdimento do dinheiro apreendido, pois à míngua de comprovação de sua origem lícita e diante dos fartos elementos comprobatórios de traficância, conclui-se tratar-se de proveito do tráfico desempenhado em coautoria pelos réus.
- 7 - Caso ainda não providenciada, proceda-se à incineração das drogas apreendidas, na forma do art. 524-B das NSCGJ. Devidamente periciadas as drogas, desnecessária a amostra para contraprova.

P.I.C

Sao Jose do Rio Pardo, 20 de outubro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA